

1502122-36.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... ostenta condenação criminal anterior por roubo majorado transitada em julgado em 24.05.2018, ainda não alcançada o período depurador, a qual será valorada na fase posterior da aplicação da pena a título de reincidência, não podendo ser levada em consideração como circunstância judicial desfavorável, sob pena de bis in idem (Súmula nº 241 do STJ); não há nos autos maiores ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502122-36.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502122-36.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296978/2021 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 21132881 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2090/21/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2296978 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATAS DA SILVA MULATO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra JONATAS DA SILVA MULATO (fls. 78/79), qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do Código Penal, porque, em tese, no dia 29.10.2021, por volta 22h20min, na Estrada da Constantinopla, nº 890, Pirajussara, nesta Cidade de Embu das Artes, subtraiu para si, durante o repouso noturno, 32 latas de cerveja, 5 garrafas de vinho e 6 latas de Red Bull, mercadorias avaliadas em R\$ 200,00, bens pertencentes à adega de Nailton Batista dos Santos.

O imputado foi preso em flagrante em 30.10.2021 (fl. 4), e a prisão foi convertida em preventiva no mesmo dia (fls. 34/37).

A denúncia foi recebida em 11.11.2021 (fls. 111/112).

Regularmente citado, o denunciado apresentou resposta à acusação por intermédio de defensora constituída, refutando o teor da denúncia e arrolando as mesmas

testemunhas da acusação (fls. 136/137).

Em não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento para a presente data (fl. 149).

Na solenidade, homologada a desistência da oitiva da vítima, colheram-se os depoimentos das testemunhas comuns, interrogou-se o réu, e, uma vez encerrada a instrução processual, as partes teceram suas alegações finais oralmente (termo de audiência de fl. 176).

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão punitiva procede em parte.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 4), no boletim de ocorrência (fls. 1/3) e nos autos de exibição, apreensão e entrega e de avaliação da res furtiva (fls. 11 e 12), despontando, ainda, da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa, emergindo da prova vocal produzida nos autos.

Em solo policial, o representante legal da empresa vítima, Nailton Batista dos Santos, relatou que: é dono da adega furtada; visualizou pelas câmeras do interior do estabelecimento comercial que havia um indivíduo furtando mercadorias (bebidas); o sujeito havia adentrado no local pela janela do tipo vitrô, aproveitando-se do fato de o vidro estar quebrado; rapidamente se dirigiu até o local e flagrou o furtador saindo do estabelecimento, com as mercadorias subtraídas, tendo acionado a Polícia Militar, a qual conduziu todos à Delegacia de Polícia (fl. 7).

Tanto em solo policial (fls. 6 e 7), quanto em juízo (mídia audiovisual da audiência), os policiais militares Igor Eduardo Xavier e Kleber Alberto da Silva narraram que: foram acionados via Copom para atender ocorrência de furto em estabelecimento comercial, uma adega; chegando ao local, encontraram o proprietário com o furtador, já detido, juntamente com a res furtiva; encaminharam todos ao DP. Confrontados, não souberam dizer se o réu foi detido pelo dono da adega dentro ou fora do estabelecimento comercial.

Confesso em ambas as fases da persecução penal (fl. 8 e mídia audiovisual da audiência), o acusado enalteceu que foi flagrado pelo dono do estabelecimento comercial, em poder das mercadorias, quando ainda estava dentro da adega.

Como se vê, os relatos da vítima, das testemunhas e do acusado são congruentes e harmônicos quanto à autoria irrogada ao último.

Diversamente do sustentado pela combativa defesa, não há que se falar em crime impossível. A despeito da existência de sistema de monitoramento por câmeras no estabelecimento comercial, o réu não foi monitorado desde a sua entrada na adega, mas apenas quando iniciada a execução do crime de furto. Mesmo com o aparato de segurança, o increpado logrou se apossar dos produtos, burlando, ainda que por pouco tempo, a vigilância. Como anota CLEBER MASSON, citando a jurisprudência sedimentada sobre o tema:

(...) a existência de sistema de vigilância por câmeras ou agentes de segurança em supermercados e estabelecimentos comerciais torna mais difícil, mas não impossível, a consumação de furtos ali praticados. O agente pode burlar a vigilância e retirar o bem da esfera de disponibilidade da vítima. Caracteriza-se, portanto, a tentativa. Para o Supremo Tribunal Federal: "A existência de sistema de vigilância em estabelecimento comercial não constitui óbice para a tipificação do crime de furto". É também o entendimento consolidado na Súmula nº 567 do Superior Tribunal de Justiça: "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto". (Direito Penal: parte especial (arts. 121 a 212), v. 2, 14ª edição, Rio de Janeiro: Forense; Método, 2021, p. 333). (Negrito no original).

Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena do repouso noturno, para cuja incidência "basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no

momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime.” (STJ, AgRg no AREsp nº 1.234.013, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.08.2018). Complementa VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES:

No passado havia consistente entendimento no sentido de que o furto noturno não deveria ser aplicado se o fato ocorresse em estabelecimento comercial fechado, com o argumento de que, em tais casos, o agente estaria se valendo da ausência de pessoas no local e não do sono dos moradores. Atualmente, entretanto, os julgados do Superior Tribunal de Justiça apontam em sentido contrário, autorizando o aumento da pena em razão da menor vigilância decorrente do repouso da coletividade. A propósito: “Incide a causa de aumento de pena referente à prática do crime de furto durante o repouso noturno ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial ou residência desabitada, tendo em vista a maior vulnerabilidade do patrimônio. Precedentes” (AgRg no REsp 1.582.497/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 15-8-2017, DJe 28-8-2017); “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que 'incide a majorante prevista no § 10 do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para estabelecimentos comerciais. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando' (HC 191.300/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012). Precedentes” (AgRg no REsp 1.546.118/ MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 2-2-2016, DJe 10-2-2016). É claro, porém, que, se o furto ocorrer em estabelecimento comercial aberto, onde existem pessoas trabalhando, não se aplicará o instituto. Também não incide se o fato ocorre em bares ou casas noturnas em funcionamento.” (Direito penal esquematizado – parte especial – 10. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 365). (Negritei).

Portanto, tendo o furto sido cometido antes do alvorecer (mais precisamente, às 22:18 horas: fl. 1), incide a causa de aumento em apreço.

De outro vértice, é de ser reconhecida a prática do delito na sua forma tentada (art. 14, II, do Código Penal).

A respeito do momento consumativo do crime de furto, preleciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

Trata-se de tema polêmico e de difícil visualização na prática. Em tese, no entanto, o furto está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. É imprescindível, por tratar-se de crime material, que o bem seja tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, na posse tranquila do agente. Se houver perseguição e, em momento algum, conseguir o autor a livre disposição da coisa, trata-se de tentativa. Não se deve desprezar essa fase (posse tranquila da coisa em mãos do ladrão), sob pena de se transformar o furto em um crime formal (onde se pune unicamente a conduta e não se demanda o resultado naturalístico). No mesmo sentido, Muñoz Conde, Derecho penal – Parte especial, p. 359.

Esclarece Laje Ros: “o furto consiste, de um ponto de vista material, em apoderar-se da coisa alheia que se encontra em poder de outro, que, por apoderamento, resulta desapoderado daquela coisa. Isso implica dizer que o objeto deixou de ser detido por este e que é detido pelo ladrão. Também importa entender que o apoderamento implica que o objeto deixou de pertencer a uma esfera de custódia e incorporou-se à de quem se apoderou” (La interpretación penal en el hurto, el robo y la extorsión, p. 97). Há, basicamente, quatro teorias para fundamentar a consumação do furto: a) o furto se consuma apenas com o toque na coisa móvel alheia para apoderar-se dela (teoria do contato); b) concretiza-se no momento da remoção ou mudança de lugar, vale dizer, o furto se consuma apenas quando a coisa é removida do local onde fora colocada pelo proprietário; c) distingue a remoção em dois momentos: a apreensão (aprehensio) e o traslado de um lugar a outro (amotio de loco in locum); para a consumação, requer-se que a coisa seja trasladada do lugar

onde estava a outro local, somente assim se completa a subtração (ablatio). Há de sair da esfera de vigilância do dono; e d) o furto se consuma quando a coisa é transportada pelo agente ao lugar por ele pretendido (eo loco quo destinaverat) para colocá-la a salvo (ob. cit., p. 207-208).

A mais adequada teoria, conforme sustentamos anteriormente, é a terceira, dependente da apreensão, seguida da amotio, para que se dê a ablatio. Sem apreensão, remoção de um lugar a outro – fora das vistas da pessoa ofendida – inexistente subtração, logo, consumação do crime. (Manual de Direito Penal, 16ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 618).

Em uma palavra: delito material que é, a consumação do furto requer a perda, mesmo que momentânea, do bem subtraído (adoção da teoria da amotio).

No caso vertente, não houve a perda, ainda que momentânea, da res furtiva. Embora tenham sido praticados os atos executórios, com o fito de subtrair coisa alheia móvel, o delito não foi levado a efeito por circunstâncias alheias à vontade do agente – ação do dono da adega –, divisando-se a figura da tentativa (art. 14, II, do Código Penal).

Levando em consideração o iter criminis percorrido, reputo que o agente se aproximou de forma estreita da consumação do delito – ele já havia adentrado no estabelecimento comercial e recolhido a res furtiva quando foi surpreendido pelo proprietário do estabelecimento comercial –, de modo que a diminuição da pena deve ser no grau mínimo de um terço (art. 14, parágrafo único, do Código Penal).

Nesse cenário fático-probatório, a conduta do réu se amolda, formalmente, ao disposto no art. 155, § 1º, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Assentada a tipicidade formal do delito, passo à análise da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à espécie, causa supralegal de exclusão da tipicidade material.

O princípio da insignificância deflui do princípio da intervenção mínima, preconizando que não há crime quando a conduta se revela como insignificante, ou seja, é incapaz de lesar ou de sequer colocar em perigo o bem jurídico tutelado pelo tipo penal. Tem por objetivo, assim, proceder a uma interpretação restritiva da lei penal, diminuindo o alcance da intervenção penal.

Para a sua aplicação, a jurisprudência das cortes superiores exige a presença de requisitos objetivos (ligados ao fato praticado pelo agente) e subjetivos (tocantes ao agente e à vítima). Na primeira ordem de requisitos despontam: (i) a mínima ofensividade da conduta; (ii) a ausência de periculosidade social da ação; (iii) o reduzido grau de reprovabilidade da conduta; e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica. No rastro dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, esses vetores devem coexistir, merecendo análise conglobada, no caso concreto. No aspecto subjetivo, entram em linha de conta as condições pessoais do agente (reincidente, criminoso habitual, militar, entre outras) e da vítima (máxime a extensão do dano e o valor sentimental do bem).

Particularmente em relação ao furto, a aplicação do princípio não pode ter como parâmetro apenas o valor da res furtiva, devendo ser sopesadas as circunstâncias do fato e o reflexo da conduta do agente no âmbito da sociedade, para então se decidir sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela. Ademais, a presença de circunstâncias qualificadoras denota maior reprovabilidade da conduta do agente, arredando a incidência do princípio da insignificância (nessa linha, confira-se, por todos: STJ, HC 351.207/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 28.06.2016).

À luz dessas premissas, não reputo mínima a ofensividade da conduta, tampouco reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento de agente reincidente em crime patrimonial que ingressa em estabelecimento comercial, durante o repouso noturno, para a subtração de bens, ficando, pois, afastada a aplicação do princípio da insignificância.

Logo, ausentes excludentes de ilicitude e dirimentes de culpabilidade, e inexistindo causas de extinção da punibilidade, a responsabilização criminal do acusado como incurso no art. 155, § 1º, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, é de rigor.

Passo a dosar a pena aplicável ao réu, em atenção ao sistema trifásico perfilhado

pelo Código Penal (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que: a culpabilidade é normal à espécie; consoante se extrai da certidão de fls. 164/165, o réu ostenta condenação criminal anterior por roubo majorado transitada em julgado em 24.05.2018, ainda não alcançada o período depurador, a qual será valorada na fase posterior da aplicação da pena a título de reincidência, não podendo ser levada em consideração como circunstância judicial desfavorável, sob pena de bis in idem (Súmula nº 241 do STJ); não há nos autos maiores informações sobre a personalidade do agente; o motivo, obtenção de lucro fácil, é inerente ao tipo subjetivo do furto; as circunstâncias e as consequências do crime também são inatas ao tipo penal, no seu aspecto objetivo, não merecendo valoração; e o comportamento da vítima é circunstância neutra ou favorável.

À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no piso de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo) vigente à época dos fatos, pois não há informações precisas sobre a situação econômica do réu (arts. 49 e 60 do Código Penal).

Na segunda fase, concorrem as circunstâncias atenuante da confissão espontânea perante as autoridades policial e judicial (art. 65, III, "d", do CP), ainda que parcial, que foi utilizada para a formação do convencimento deste julgador (Súmula nº 545 do STJ), e agravante da reincidência (art. 61, I, e 63, ambos do CP), já que, conforme supra se adiantou, o réu foi condenado definitivamente por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), condenação ainda não alcançada pelo período depurador.

Atento à compreensão pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do EREsp nº 1.154.752, em 26.05.2012, compenso a atenuante e a agravante em testilha, posto serem igualmente preponderantes, ex vi do disposto no art. 67 do CP. Remanesce, pois, a pena tal qual dosada anteriormente.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de 1/3 relativa à prática de crime durante o repouso noturno (§ 1º do art. 155 do CP), de sorte que passo a dosar a pena em 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

De outro lado, há de ser reconhecida a modalidade tentada do delito (art. 14, II, do Código Penal), razão pela qual diminuo a pena no patamar mínimo legal de 1/3 - consoante fundamentação supra -, tornando-a definitiva em 10 meses e 20 dias de reclusão e 9 dias-multa.

A teor da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, seria o caso de adotar, em linha de princípio, o regime prisional semiaberto para início do resgate da pena corporal, porquanto inferior a quatro anos e favoráveis as circunstâncias judiciais. Sucede que o réu já se encontra preso preventivamente desde 30.10.2021 (fl. 165), tendo cumprido mais de 7 meses de reclusão, o que impõe a aplicação do instituto da detração, por força do disposto nos arts. 387, § 2º, do Código de Processo Penal e 112, IV, da Lei nº 7.210/1984, em dicção conjunta. Como vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "com o advento da Lei 12.736/12, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado" (HC n. 443.419/SP, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.06.2018, DJe 12.06.2018). Fixo, pois, o regime aberto para início do cumprimento da pena corporal. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO QUALIFICADO (ART. 155, §§ 1º e 4º, I, CP).

Sentença condenatória. Recurso da defesa. Mérito. Materialidade e autoria satisfatoriamente demonstradas. Crime impossível. Não ocorrência. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Ausência de comprovação, porém, da qualificadora, já que o laudo pericial não identificou o rompimento ou destruição de obstáculo.

Dosimetria. Redução do percentual de aumento da primeira fase, em respeito ao princípio da proporcionalidade. Compensação integral entre confissão e reincidência. Precedentes do STJ. Regime inicial de cumprimento da pena. Aplicação

do art. 387, §2º, do CPP, para fixar o regime aberto. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1500235-42.2020.8.26.0631, 13ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcelo Semer, j. 20.09.2021); e

FURTO TENTADO - Quadro probatório seguro e coeso Confissão do réu com amparo no relato das testemunhas - Princípio da insignificância - Inaplicabilidade - Crime impossível não configurado - Condenação mantida - Penas que não comportam reparo - Reconhecimento da tentativa, que autorizou a redução máxima de 2/3, ante o iter criminis percorrido - Regime aberto mais adequado à espécie, em razão da aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP - Recurso parcialmente provido (voto nº 41761). (TJSP, Apelação Criminal nº 1502035-33.2019.8.26.0537, 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Newton Neves, j. 27.03.2020).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mercê da reincidência do réu em crime de natureza patrimonial, de maneira que considero a fixação de penas alternativas insuficiente para prevenção e reprovação do delito, não sendo recomendável (art. 44, inciso II e § 3º, do CP).

Simetricamente, a reincidência em crime doloso obsta a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu JONATAS DA SILVA MULATO, já qualificado nos autos, como incurso no art. 155, § 1º, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 9 dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

Apenado com sanção corporal a ser inicialmente cumprida em regime aberto, cenário incompatível com a manutenção da prisão preventiva (vide, por todas, a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, in Código de Processo Penal Comentado - 19. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 792, encampada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça esposado no Informativo nº 554 da sua jurisprudência), REVOGO a custódia cautelar, concedendo ao acusado o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, do CPP), mediante o cumprimento das medidas cautelares de: (i) comparecimento periódico em juízo, mensalmente, a fim de informar e justificar suas atividades; (ii) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização deste juízo; e (iii) recolhimento domiciliar no período noturno, das 22h00 às 6h00, e nos dias de folga (arts. 282, § 5º, e 319, ambos do CPP). EXPEÇA-SE alvará de soltura clausulado, para que o réu seja colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, do CPP), tanto porque os bens furtados foram recuperados, quanto porque não houve pedido expresso da acusação.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Intime-se a vítima do teor deste julgado (art. 201, § 2º, do CPP).

Considerando que as partes expressamente desistiram do recurso (termo de audiência), certifique-se o trânsito em julgado e na sequência: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados; (b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do domicílio eleitoral do acusado, para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF), e para efeitos de inelegibilidade; (c) expeça-se a documentação necessária para a execução da pena; e (d) oficie-se ao IIRGD, para fins de registro dos antecedentes criminais do acusado; e (e) remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo da multa, intimando-se, em seguida, o acusado para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (art. 50 do Código Penal).

P. I. C.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Embu das Artes, 07 de junho de 2022.

MARGEM DIREITA